TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
GIUDICE DOTT. PAOLO D'AVINO

R.G. N. 65945/2021 MISURE CAUTELARI

TRATTAZIONE SCRITTA DEL 21 MARZO 2022

Visto e richiamato il proprio provvedimento del giorno 2.9.2021, con il quale è stata disposta l'odierna trattazione scritta;

rilevato che le parti (entrambe costituite) hanno depositato telematicamente le relative note con le rispettive istanze, pronunzia la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per provvedimento d'urgenza *ante causam* proposto

da

Parte_1 (cod. fisc. *Part C.F._1*), in persona dell'ammin.re in carica, *Controparte_1 [...]* in persona dell'accom.ria *pro tempore* *Parte_2* , rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Cirilli, presso il quale elett.te domicilia sempre in *Pt_1* Via Maria Barbara Tosati n. 26, giusta procura su foglio separato depositato telematicamente con il ricorso introduttivo,

contro

Controparte_2 (cod. fisc. *CodiceFiscale_2*), residente in Alatri (FR), Via dei Villini n. 9, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano De Renzis, presso il quale elett.te domicilia in *Pt_1* Corso Trieste n. 150, giusta procura su foglio separato depositato telematicamente con la memoria costitutiva,

IL GIUDICE

letti gli atti;

rilevato che il Condomino ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler ordinare in via d'urgenza alla condomina *Controparte_2* (proprietaria del locale a uso negozio posto al piano terreno, distinto col n. 8 e con accesso da Via Casal Selce n. 344), alla quale imputa di aver proceduto (nell'ambito di consistenti lavori di ristrutturazione eseguiti anche a fini di mutamento della destinazione d'uso) a inglobare, all'interno di una volumetria chiusa, la colonna montante di adduzione del gas condominiale originariamente installata, invece (nel pieno rispetto della normativa di sicurezza), all'aperto con posa a vista, il ripristino dei luoghi per i quali è causa nello *status quo*

ante, previa rimozione del manufatto di ampliamento della unità identificata in NCEU di *Pt_1* fg. 343, p.lla 205, *sub.* 504 per mq. 43,85, o, in via gradata, la ricostituzione delle condizioni di sicurezza mediante opportuna areazione dei locali anche attraverso la rimozione dei pannelli di *plexiglas* di chiusura e/o l'astensione dall'apposizione di (altre) chiusure ai suddetti locali al fine di mantenerli adeguatamente areati;

rilevato, altresì, che si è costituita la resistente, eccependo, preliminarmente, l'inesistenza della notificazione del ricorso del *Parte_1*, siccome eseguita, per mezzo del servizio di PEC, presso un indirizzo di destinazione "privato", non inserito in pubblici elenchi; respingendo l'avverso assunto che siano stati compiuti alcuna appropriazione di parti comuni (la piccola corte esterna – o terrazza a livella – essendo sempre stata di pertinenza dell'unità immobiliare e, perciò, di proprietà esclusiva) o alcun abuso edilizio (la trasformazione/ampliamento in questione dovendosi far risalire alla propria dante causa – *Controparte_3* – ed essendo stati, comunque, correttamente condonati, senza opposizioni al riguardo); replicando di aver scoperto soltanto durante lavori di ristrutturazione l'esistenza delle tubazioni di condotta del gas, fatiscenti e alloggiate nel controsoffitto, e di aver – ripetutamente quanto inutilmente – offerto al *Parte_1* – anche per via giudiziaria – soluzioni alternative per il passaggio delle stesse (soluzioni elaborate, per altro, anche dalla società di gestione della rete, *Org_1*, senza, tuttavia, mai ricevere alcun riscontro utile; contestando, comunque, l'ammissibilità dell'azione esperita *ex adverso* (in difetto sia di strumentalità rispetto alla non specificata tutela di merito sia di … residualità – rispetto alle azioni possessorie e nunciatorie – sia del *periculum in mora*) e proponendo, in via subordinata (per il solo, denegato caso «in cui dovessero essere respinte le eccezioni preliminari e dovesse essere accertata l'esistenza di una servitù di passaggio di conduttore del gas» a carico della propria unità immobiliare,

«domanda riconvenzionale di spostamento della servitù medesima *ex* art. 1068, comma 2, cod. civ.»;

ritenuto, con riguardo alla specifica azione cautelare esperita dal ricorrente *Parte_1* che:

aa) anzitutto, il pur rilevato vizio della notificazione del ricorso introduttivo non appare aver concretamente comportato una violazione del contraddittorio, poiché risulta che la resistente abbia potuto – costituendosi – esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, e, in ogni caso, non può considerarsi utile la rinnovazione della notificazione medesima, il ricorso non essendo meritevole di accoglimento;

ab) ciò posto, non soltanto «la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio in tema di azioni negatorie o confessorie *servitutis* sussiste tutte le volte in cui sorga controversia sulla esistenza e sulla estensione di servitù prediali costituite a favore o a carico dello stabile condominiale nel suo complesso o di una parte di esso, in quanto in tali ipotesi le servitù medesime vengono esercitate o subite indistintamente da tutti i condòmini e non singolarmente da ciascuno di essi» (e non è esclusa neppure «nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere comuni o … la eliminazione di ostacoli che impediscano o turbino l'esercizio della servitù medesima, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condòmini»: cfr. Cass. 7 gennaio 2019, n. 128), ma, quanto alle «azioni reali da esperirsi contro i singoli condòmini o contro terzi e dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale», che siano riconducibili nel novero degli atti meramente conservativi, l'amministratore è investito di autonoma legittimazione attiva *ex* art. 1130, n. 4, c.c. (mentre necessita della «previa autorizzazione dell'assemblea, *ex* art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.», quando le azioni medesimo esulino da quell'ambito:

cfr. Cass. 7 ottobre 2020, n. 21533);

ac) sennonché, assolutamente irrilevante ai fini della decisione (tanto in sede cautelare quanto in sede di merito) della controversia fra le odierne parti è la questione della validità del condono e della *Org_2* , poiché è ben noto che la c.d. "concessione in sanatoria" ottenuta dal proprietario costruttore in esito all'accertamento di conformità (agli strumenti urbanistici vigenti sia nel momento della costruzione sia in quello della domanda) di qualsivoglia intervento edilizio rilevante eseguito senza originario titolo autorizzativo valido (permesso di costruire, "segnalazione certificata di inizio attività" o "comunicazione di inizio lavori asseverata") ha il mero effetto di rimuovere un ostacolo pubblicistico all'esercizio dello *ius ædificandi*, ma non può mai (nemmeno se ritenuta legittima dal Giudice amministrativo) incidere sull'assetto dei rapporti con i proprietari di immobili vicini, diversi da quello oggetto d'intervento, ai quali spetta sempre piena tutela (reale – quando prevista – e risarcitoria) dei loro diritti (espressamente, l'art. 11, comma 3, del dPR n. 380/2001 dispone che «Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi») davanti al Giudice ordinario (cui compete la valutazione *incidenter tantum* della legittimità dell'eventualmente rilasciato titolo autorizzativo dell'attività costruttiva, attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, mentre se la domanda risarcitoria è «diretta anche nei confronti della P.A. … per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale», allora sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo: cfr. Cass., 5 gennaio 2018, n. 166);

ad) la «precipua finalità» perseguita dal *Parte_1* ricorrente è, dichiaratamente, quella, «una volta demolito l'ampliamento ottenuto "*deus noscit quos*", di riporre sulla facciata della corte interna le tubazioni di adduzione del gas, oggi indebitamente inglobate, e con il rischio o di interruzione dell'utenza in caso di verifiche o, ancor peggio, di eventi

sinistrosi di sicuro tragico esito in caso di perdite», ma non è stata prospettata un'apprezzabile minaccia, *diretta e attuale*, di pregiudizio (grave e irreparabile) per *diritti personali quanto meno a funzione non esclusivamente patrimoniale* e la cui insorgenza si ponga in relazione temporale sufficientemente ravvicinata con il ricorso alla tutela cautelare (così da poter vanificare, invece, il ricorso – ancorché tempestivo – a quella ordinaria), ma, anzi, ha trovato sicuro riscontro processuale l'offerta della proprietà servente di soluzioni per il passaggio alternativo della tubazione *de qua*, su nessuna delle quali, però, le parti hanno trovato un soddisfacente accordo fra loro;

ae) sempre con riguardo, infine, al requisito del *periculum in mora* (che, per la sua caratteristica inerenza alla tutela cautelare – a differenza dell'apprezzamento anche in termini soltanto probabilistici del *fumus boni iuris* –, deve essere delibato, con particolare rigore, in termini di vera e propria certezza), *non* appaiono configurarsi in misura adeguata (ai fini di una specifica urgenza d'intervento: la "questione", sottoposta alla cognizione del Tribunale con ricorso depositato il 13.11.2021, era insorta già nel novembre/dicembre 2018) l'*imminenza* e l'*attualità* del pregiudizio, da intendersi, l'una, come incombente minaccia del pericolo (nel senso che il relativo *iter* di produzione fenomenico/causale deve apparire già, se non proprio iniziato, almeno univocamente avviato) e, l'altra, come *congruenza fra la situazione lesiva lamentata e la reazione difensiva alla stessa* (nel senso che quella deve essere recentemente insorta e questa deve essere pronta e tempestiva, in modo da attribuire all'invocato rimedio di giustizia effettiva incisività – mentre si conviene, per lo più, sull'esclusione di tale congruenza allorquando sia oramai trascorso un periodo di tempo più o meno pari a quello che sarebbe occorso per un efficace esperimento della tutela ordinaria di merito del diritto controverso, a meno che, beninteso, non sussistano concreti rischi di intensificazione o reiterazione della situazione

medesima o non si paventino nuovi e diversi o semplicemente ulteriori effetti dannosi –);

ritenuto, per altro e quanto alla *controtutela* richiesta, in via «riconvenzionale» (sebbene non esista, in generale, un formale divieto di estendere – con iniziative "incrociate" – l'oggetto del procedimento cautelare, l'esercizio dell'azione *in reconventionem* – con il conseguente *simultaneus processus* – può essere ritenuto, in concreto, inammissibile dal Giudice, non soltanto – allo stesso modo che nel giudizio ordinario – in assenza di collegamento oggettivo fra le contrapposte domande – non necessariamente fondato su un titolo dipendente da quello fatto valere dal ricorrente, come richiesto, ad altri fini, dall'art. 36 cod. proc. civ. –, ma anche quando se ne debba verosimilmente escludere la specifica e imprescindibile connotazione di urgenza, per il fatto stesso della "posposizione temporale" e della prospettazione meramente reattiva al ricorso avversario), dalla resistente, che:

Co) la domanda diretta a ottenere l'accertamento, la costituzione o la modificazione di una servitù «su un fondo di proprietà dei condòmini di un edificio va proposta nei confronti di ciascuno degli stessi, che soli possono disporre del diritto in questione (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), e non nei confronti dell'amministratore del condominio, il quale, carente del relativo potere di disporne, è perciò sfornito di *lægitimatio ad causam*, oltre che di *lægitimatio ad processum* per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c.» (cfr. Cass., 18 settembre 2020, n. 19566);

bb) la tutela richiesta appare, di per sé e già in astratto, non poter assumere concreta connotazione di pericolo di danno imminente e irreparabile (requisito – come appena ricordato – imprescindibile della tutela cautelare d'urgenza) ed essere, perciò, destinata, per sua natura, alla trattazione e

definizione nella sola, eventuale sede di cognizione ordinaria;

ritenuto, infine, quanto al regolamento delle spese, che, in considerazione della soccombenza reciproca, le stesse possano essere integralmente compensate fra le parti,

P. Q. M.

RIGETTA

il ricorso d'urgenza proposto dalla società amministratrice del *[...]* *Parte_1* ;

DICHIARA

inammissibile l'azione "riconvenzionale" esperita dalla resistente *CP_2* *[...]*

COMPENSA

integralmente fra le parti le spese del procedimento cautelare;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, 121.10.2023, IL GIUDICE